

瑞士抽象法規審查制度*

—— 以瑞士蘇黎世邦行政法院裁判為例

林明鏘**

目次

壹、前言：臺灣未來的抽象法規 審查制度	一、前言：非典型之司法任務
貳、瑞士聯邦及各邦抽象法規審 查制度	二、審查標的（撤銷標的）
一、定義及目的	三、人民提起訴訟之合法要件 （Legitimation）
二、演進及擴大	四、法院裁判權限
三、在各邦的施行狀況	五、訴訟費用
參、瑞士抽象法規審查與個別行 政行為審查之比較	六、無償之司法扶助
	七、停止執行效力
	肆、結語

* 謹以本論文敬獻給故恩師吳庚教授，以緬懷吳老師重視法比較之學術先行典範。

〔責任校對：陳怡瑾〕。

** 國立臺灣大學法律學院蔡萬才、連震東法政講座教授、臺大特聘教授、國立臺灣大學法律學院歐洲聯盟法律中心主任。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/70510102.pdf>。



壹、前言：臺灣未來的抽象法規審查制度

我國司法院大法官於民國105年12月9日作成之司法院釋字第742號解釋文認為：「都市計畫之訂定（含定期通盤檢討之變更），影響人民權益甚鉅。立法機關應於本解釋公布之日起二年內（即民國107年12月9日）增訂相關規定，使人民得就違法之都市計畫，認為損害其權力或法律上利益者，提起訴訟以資救濟。¹」由於都市計畫之訂定及變更，依司法院釋字第156號及742號解釋，均認其性質屬「法規」，從而，民國107年12月9日前，我國現行之行政訴訟法即應依司法院釋字第742號解釋文之意旨，增訂都市計畫「抽象法規審查制度」，因為我國現行之行政訴訟法僅有具體違法行政處分之救濟規定，並無「抽象」或「具體」的「法規審查制度」²，目前僅司法院大法官得進行「抽象」（機關或法官聲請）或「具體」（大部分之人民聲請釋憲案件），所以行政訴訟法之主管機關司法院乃組成「行政訴訟規範審查制度研究修正委員會」定期開會討論如何明文化都市計畫之「抽象法規審查」訴訟程序（擬規定於行政訴訟法第二編第五章修正草案第237條之18至第237條之31內），為使其討論內容有更多元的考察對象，而不僅是只討論關心德國行政程序法第72條至第78條之「計畫確定程序」（Planfeststellungsverfahren）³或德國行政法院法第47條之「規範審查程序」

1 有關司法院釋字第742號解釋之整體性評析，併請參見林明鏘，都市計畫審查通盤檢討變更之司法救濟——評析釋字第742號解釋，月旦裁判時報，68期，頁60-77（2018年）。

2 「抽象法規審查」與「具體法規審查」的區別在於「法院」（含憲法法院）在審查法規是否合乎其上位規範時，聲請人有無具體個案（即行政處分）之存在，若無具體個案存在，則稱為「抽象法規審查」；反之，則稱為「具體法規審查」。法規若為「行政命令」，依司法院釋字第137號及第216號解釋，一般法官可享有具體的法規審查權，但僅能排斥不用，而不得加以撤銷或為無效宣告。

3 有關德國行政程序法第72條至第78條之「計畫確定裁決程序」或「計畫許可」程序（Plangenehmigung），得參見Werner Neumann, in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), VwVfG Kommentar, 9. Aufl., 2018, § 72 Rn. 72 ff.

(Normenkontrollverfahren)⁴而已，故乃以「瑞士」(聯邦及蘇黎世邦)的抽象法規審查制度介紹分析，供我國在未來立法時，得有更多的周密考量及更多元之比較考察對象。

瑞士在歷史傳統上，係由各邦團結組合成「聯邦政府」(唯無設聯邦總統)，聯邦雖設有一級一審「聯邦行政法院」⁵，但各邦之行政法院亦享有相當大之審判權限，因此，除聯邦行政法院法之相關規定說明外，並輔以Zürich邦(蘇黎世)2010年甫引進「行政審判法」(Verwaltungsrechts-Pflegegesetz)之抽象法規審查制度⁶，以茲周全討論分析我國未來法規審查制度(都市計畫)之合宜設計，合先敘明。

貳、瑞士聯邦及各邦抽象法規審查制度

一、定義及目的

瑞士「聯邦行政法院法」或各邦之「行政審判法」所指稱「抽象法規審查」係指：人民聲請行政法院審查系爭之行政命令是否與

⁴ 有關德國行政法院法第47條之詳細逐條說明，得參見Wolf-Rüdiger Schenke/Ralf P. Schenke, in: Kopp/Schenke (Hrsg.), Verwaltungsgerichtsordnung: VwGO, 23. Aufl., 2017, § 47; Jörg Schmidt, in: Eyermann (Hrsg.), Verwaltungsgerichtsordnung, 15. Aufl., 2019, § 47 Rn. 1 ff. 中文翻譯得參見傅玲靜，都市計畫救濟制度之變革及審查密度——「以行政訴訟法修正草案」為中心，第16屆公法研討會，最高行政法院、東吳大學法學院公法研究中心主辦，頁10(2019年5月4日)。

⁵ 瑞士聯邦行政法院於2007年1月1日設立前，乃由瑞士聯邦法院統一審理行政事件。瑞士行政法院設立於瑞士首都伯恩(Bern)，2007年約處理8,000件行政事件。Vgl. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Ausgewählte prozessrechtliche Fragen im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht (im folgenden ZBl) 2008, S. 1 (2).

⁶ Vgl. Andreas Conne, Abstrakte Normenkontrolle im Kanton Zürich: Überblick und Vergleich mit der Einzelaktkontrolle, ZBl 2014, S. 403 (403 f.).

上位階之法規範相合致 (Übereinstimmung einer Norm)，但聲請人起訴時並未受到行政機關具體適用系爭法規範而作成之一個行政處分。換言之，只要在系爭法規範公布後（含生效前），人民即得聲請行政法院為抽象法規審查⁷，與我國都市計畫之法規抽象審查極為相似，我國行政訴訟法修正草案增訂一年內須提出訴訟，逾期即不合法，亦屬抽象法規審查之類型。

聲請行政法院為抽象法規審查之目的，除得以貫徹法規範位階理論，確保法規範秩序之一致性外，並且具有「預防性」之目的 (Präventive Zweck)；但是此種訴訟目的，原則上並沒有「壓制性」的目的 (repressive Zweck)⁸，申言之：抽象規範審查制度的主要目的，乃預防因不合法狀態，而造成人民權利或法律上利益可能受損，而非積極排除該法規。例如：蘇黎世大學醫學系學生，對於蘇黎世大學提高學費之「學費收取標準」(屬於大學自治性命令)，提起抽象規範審查，其主要目的乃在於預防聲請人下學期學費會受到所屬大學較高額之收取而會受到不利益，而非排除或壓抑該「收取標準」⁹，與我國都市計畫法院得對系爭標的得為全部或一部無效諭知，並不相同。

二、演進及擴大

「具體」的規範審查制度發源甚早，英國早在1610年即有判例出現拒絕適用與國會法律相互抵觸之行政命令案例¹⁰；美國1803年更由首席大法官 John Marshall 創造出「具體」的「違憲審查制度」¹¹；而「抽象」之違憲審查則始源於1874年的瑞士，瑞士是全

⁷ Vgl. *Conne* (Fn. 6), S. 404.

⁸ Vgl. *Conne* (Fn. 6), S. 404.

⁹ 此一案例為聯邦法院裁判，vgl. BGE 139, I, 138.

¹⁰ 此即為英國法官 Edward Coke 在 *Bonham's* 案件中，所創造出的具體法規審查原則。Vgl. *Conne* (Fn. 6), S. 404.

¹¹ 1803年美國首席大法官 (Chief Justice) Marshall 於 *Marbury v. Madison* 案中，創

世界第一個國家允許個人得提起「抽象之憲法訴願」(staatsrechtliche Beschwerde)(或德文直譯為國家法上之訴願)其目的在於確保瑞士聯邦法之優先性及統一各邦不同之規定，所以此種憲法訴願原則上不得聲請撤銷聯邦法律或命令(參見瑞士聯邦憲法第189條第4項及190條規定)；而且瑞士各邦法院原則上不得進行抽象的法規審查，理由係已有聯邦法之擔保審查制度，可以進行抽象法規審查¹²。

三、在各邦的施行狀況

瑞士起因其司法改革，2007年1月起在聯邦憲法第29a條之新規定，為確保人民有效權利救濟途徑，所以開始允許各邦行政法院可以進行抽象之司法審查，根據瑞士Zürich邦行政法院法官Andreas Conne的統計分析，目前各邦的抽象法規審查制度共分成下列三種不同類型¹³：

第一種類型：行政法院僅能針對邦之「自治章程」進行抽象法規審查者。例如：Bern（伯恩）邦及2010年6月底前的Zürich邦，是採最狹義之抽象法規審查，僅限於鄉鎮市之自治章程。

第二種類型為：除自治章程外，並允許針對邦之行政命令進行審查者。例如：現今（2010年7月1日以後）Zürich邦、Basel-Stadt邦、Basel-Landschaft邦、Schaffhausen邦及Luzern（洛桑）邦，係處於中間類型者。

第三種類型：乃最廣之抽象法規審查。申言之：行政法院之抽

造出具體的違憲審查，也誕生了憲法審判制度。Vgl. Conne (Fn. 6), S. 404.

¹² Vgl. Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2. Aufl., 1994, S. 7 f. 瑞士於1920年創造出某一個特殊法院，審查憲法上之爭議（含法規審查），亦屬全世界第一個國家，但提起權人係國家機關及國會中之少數黨，並非許由人民提起。

¹³ Vgl. Conne (Fn. 6), S. 405-407.

象法規審查除得審理邦自治章程、邦行政命令外，並得審查「邦法律」，例如：Nidwalden 邦、Aargau 邦、Waadt 邦、Jura 邦及 Graubünden 邦，擴大邦行政法院抽象法規審查權限及範圍，藉以貫徹保障（充分）人民之權利救濟途徑。

綜合言之，隨著瑞士2007年之司法改革演進，目前上從邦憲法，下至邦自治章程，在瑞士都可以受到國會或法院之抽象規範審查，只是其審查機關或法院因審查標的而有所不同，得以下表圖示之¹⁴。

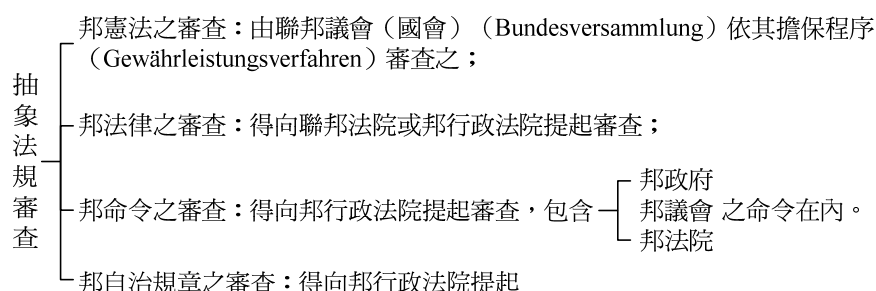


圖1 瑞士抽象法規審查表

資料來源：作者自製。

以Zürich邦為例，因為擴大邦行政法院之抽象法規審查權限，所以首先在該邦憲法第79條第2項增訂擴大邦行政法院之權限（自2005年2月27日起施行），其他立法技術，則大部分準用以前邦行政法院得審查邦自治規章之相關規定，例如：有關行政法院之管轄權、法院組成、審查權限及權利教示規定等。唯一不同的是，在審查「邦命令」時須由五位法官組成（而非自治規章審查時僅需三位法官），以示慎重審查。

¹⁴ Vgl. *Conne* (Fn. 6), S. 407.

參、瑞士抽象法規審查與個別行政行為審查之比較

一、前言：非典型之司法任務

按瑞士傳統之司法任務係：法院法官針對一個已發生之具體要件事實（*Sachverhalt*），適用相關法規範後，而得出裁判結果；可是在抽象法規範審查時，法官所面臨之系爭法令規範，卻常常出現有許多「不同類型」之「要件事實」，甚至於是無數可以想像之適用類型，而非僅僅一個具體的要件事實，此時法官要評斷各種不同要件事實類型適用系爭法規範後，所產生的法效果（*Auswirkung*），是否與上位法規範相互符合？並非易事，主要係因為法令規範具有「開放性特徵」，所以法官亦可以做各種不同的詮釋，故此種司法任務，乃屬非典型的狀況；與確定事實→適用法律→得出裁判結果的傳統三段論法極不一致，從而法官在面臨抽象法規範審查案件時，如何找尋出其不同於審查行政處分之審查標準，即極具關鍵性。因為具體審查與抽象審查存在許多本質上之差異性¹⁵。此種本質上之差異性，擬分別就審查標的、人民提起抽象法規審查之合法要件（即訴訟要件）、法院裁判權限、訴訟費用、無償司法扶助及執行停止效力，分別臚列分項加以比較，以便在我國實際立法或修法時得確認準用或不準用具體行政行為審查之相關規範或理論。

二、審查標的（撤銷標的）

如前所述，在具體行政行為審查之標的，在瑞士僅限於行政處分（含計畫確定裁決）¹⁶或一般處分，例如：法令規定某藥物之價

¹⁵ Vgl. *Kaspar Plüss*, Kognition im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle, ZBI 2014, S. 420 (423 ff.).

¹⁶ 我國行政程序法第164條第1項之「確定計劃裁決」，因仿德國行政程序法第47條規定，所以其性質即屬行政處分。Vgl. *Neumann* (Fn. 3), § 74 Rn. 17.

格或博物館之門票或老人安養院之就養價格目錄表 (Tarifstufen) 等，即屬一般處分¹⁷，而抽象法規審查之標的卻是一般性之「特定法規」，不具有「個別性」或「得特定性」，反而是具有「一般性」、「抽象性」(generell-abstrakte) 的性質，例如：地方性之「停車場管理辦法」或「行動電話基地台設置標準」……等，此種標的的審查，尤其是有關「空間計畫法令」(Raumplanungsrecht)，特別困難加以審查，因為其通常具有高度開放性及行政裁量空間，行政法院如何認定該抽象一般法令規範，與其上位法規範不一致，即非易事。例如：土地使用分區管制計畫 (Nutzungsplänen) 究竟屬於個別行為之審查或抽象規範審查，其區別標準 (即「得特定性」與「一般性」之區別標準) 何在？即甚為困擾瑞士行政法院¹⁸。

三、人民提起訴訟之合法要件 (Legitimation)

人民針對特定具體 (或得特定具體) 之行政行為提起撤銷訴訟之合法要件 (即訴訟要件)，首先要審查提起訴訟之人民，是否因個別行政行為而其權利或法律上之利益受即時 (現在) 之侵害 (aktuelles Betroffensein)，尤其要評價起訴人民與具體行政行為彼此間之關係而定 (得並參閱Zürich邦行政審判法第21條第1項及同法第49條規定)；而抽象法規審查提起之人民，僅須具備有「可能」權利或法律上利益受影響者 (Virtuelles Betroffensein)，即為已足。申言之，只要提起人民存在有一個最起碼的影響「可能性」(minimale Wahrscheinlichkeit)，即人民遲早會有一次受到系爭法規範的直接影響者，即構成有值得受保護之利益 (schutzwürdige Interessen) (併得參閱瑞士聯邦法院法第89條第1項之規定)，例如：農業用途之土地所有權人針對「洪水防制辦法」之新規定，提起抽象法規審查，因其農地使用，未來可能因洪水防制辦法新規定

17 Vgl. *Conne* (Fn. 6), S. 407.

18 Vgl. *Conne* (Fn. 6), S. 407.

之防洪區劃設而受到限制或影響，即符合訴訟合法要件。而毋庸再考量該所有權人現在是否在其農地有從事農業之經營活動¹⁹。

四、法院裁判權限

行政法院在受理抽象規範審查時，其審查權限是否與審查具體行政處分時相同？也是一個十分重要議題。在瑞士的具體行政處分審查時，法院除具有撤銷（行政處分）功能外，並具有「替換改革功能」（*reformatorsche Funktion*），申言之：行政法院除得撤銷行政處分外，並得決定一個「新的個別行為」，藉以改變；但在抽象法規審查時，行政法院卻只享有「去除功能」（*kassatorische Funktion*），並不具有「替換功能」。簡言之：行政法院基於權力分立原則及任務分工原則，不能決定新法規之未來內容，只能確認系爭規範是否不符合上級法規之文義。行政法院雖得於判決書中，給予系爭法令規範制定者修正法令方向，但該法院意見並沒有拘束制定法規機關之效力。例如：Zürich邦行政法院於審查某鄉鎮市之「議會議事規則」時，即曾因該議事規則不符合上級法規，而曾給予修正建議²⁰。

以瑞士Zürich邦為例，依該邦憲法第79條第2項及該邦行政審判法第20條第2項之規定，邦行政法院為抽象法規審查時，原則上僅享有「保守（*Zurückhaltung*）」的審查權限，申言之：行政法院僅能指摘系爭法令違反上位法令之處加以撤銷（*Aufheben*），而基於權力分立原則，不得對法規內之裁量規範為審查或控制。例外情形有下列兩種類型，Zürich邦行政法院（及聯邦行政法院）曾宣告其與上位法規不合（*unvereinbaren*），而予以撤銷者²¹：

¹⁹ 此亦為Zürich邦行政法院之裁判見解。Vgl. VGr ZH, 26. 6. 2012, AN. 2012. 00001, E. 1.3.2.

²⁰ Vgl. *Conne* (Fn. 6), S. 411.

²¹ Vgl. *Plüss* (Fn. 15), S. 421 f.

其一為：系爭法規範之開放性過高，致形成一種無法具體化的「空白法規」(konturlose Blankettnorm)，違反法令明確性原則，而可能侵害一般人民之基本權利者。例如：聯邦法院判決曾認為Zürich邦警察法規定，允許警察得以「不特定方式」，監視所有公共場所，該規定因過度公開（開放性）(offenheit)，而被撤銷，即屬適例²²。

其二為：當系爭法規範開放性過低，「沒有」或「幾乎沒有」形成空間者，也愈容易與上位法規範不一致而被撤銷。例如：Zürich邦電影行政命令規定：進入電影院之各種最低年齡限制，因為年齡規定過於具體明確，所以被邦行政法院宣告與上級法令（即邦電影法）不一致，而被例外撤銷²³；其他如Zürich大學學費收取標準（自治規章），因提高學費之數字過於具體，幾乎沒有任何彈性空間，所以也被聯邦法院加以撤銷²⁴。

原則上，不論是聯邦（行政）法院或邦行政法院從事抽象法規審查時，大都持較「保守態度」進行審查，而且不分審查邦法律或邦命令，其裁判結果均屬相似：意即，絕大部分的抽象法規審查判決，均駁回原告之聲請，而認系爭法令合乎上級規範，尤其是面臨系爭法令規範有「規範漏洞」(lückenhaft)，或有「二種可能」的文義(zweideutig)，或規範「不清楚」(unklar)時，行政法院常以「傳統」之「合憲性解釋」(verfassungskonforme Interpretation)方法，使得邦法令處於合憲結果。例如：聯邦法院於審查Zürich邦警察法之系爭規定，認為：授權警察於「違法行為情形嚴重」(Schweres Vergehen)而有「脫逃危險者」(Fluchtgefahr)，得使用警槍之規定，依「合憲性解釋原則」，仍屬合憲之規定²⁵，只有極

22 Vgl. BGE 136, I, 87E 8. 3.

23 Vgl. VGr ZH, 26, 06, 2013, AN. 2012. 00005.

24 Vgl. BGE 139, I, 138.

25 Vgl. BGE 136, I, 331E. 8. 4. 2.; BGE 130, I 82E. 2. 1.; BGE136, I, 87E. 4. 4. etc.

為少數之例外案件，因為系爭法令規範幾乎沒有解釋空間存在，諸如：進入電影院之年齡限制規定或提高大學生學費；或標準數字規定；或法令規過度不明確，而限制人民基本權利者，才會被行政法院認與上位規範不一致，而被撤銷²⁶。

五、訴訟費用

依Zürich邦行政審判法（*Verwaltungsrechtspflegegesetz*）第65a條第1項第1句之規定，一般撤銷具體行政處分的訴訟費用（*Gerichtsgebühr*）之收費標準，應依下列規定決定之：1. 訴訟之時間花費、2. 事件之困難程度、3. 爭訟標的之價值、4. 事實上之爭訟利益。準此，在抽象法規審查標的，因其事實上影響之利益範圍甚大，可否提高其訴訟費用？在瑞士學理上即具有討論性²⁷。

持肯定論者認為：抽象法規審查庭乃由五位法官組成，而具體行政處分審查僅由三位法官所組成，所以所需成本花費較高，此外系爭法令審查判決較具體行政處分擁有較大的影響力（*grössere Auswirkungen*），例如：地方發布之土地使用分區計畫即可能影響數千上萬之住宅不動產所有權人，因此提高其訴訟費用；但瑞士實務見解則持反對見解，認為訴訟費用既然法有明文，為確保此種「法律安定性」之理由以及抽象法規審查多涉及公共利益而非僅單純私益爭訟，故仍比照具體處分審查之收費標準²⁸。

26 Vgl. *Plüss* (Fn. 15), S. 425.例外的案例有邦法令規定，只有1m²以上之廣告物才需得主管機關之許可及繳交規費，數字1m²雖十分明確，而有可能受違憲宣告，但Zürich邦行政法院卻避用法律解釋方法，而使得系爭法令標準「相對化」（即非絕對標準），而得到合憲合法判決結果。Vgl. *VGr ZH*, 2. 2.2011, VB. 2010. 00413, E. 4.3.2.

27 Vgl. *Conne* (Fn. 6), S. 411.

28 Vgl. *Conne* (Fn. 6), S. 411.

六、無償之司法扶助

依瑞士聯邦憲法第29條第3項規定，以及Zürich邦行政審判法第16條規定，在個案行政處分訴訟事件審查案件之請求無償司法扶助之要件為1. 當事人無財力（或無資力）（*Mittellosigkeit*）；2. 該事件非顯無勝訴之望者（*Aussichtslosigkeit*）；3. 該事件須強制代理；4. 需當事人提出免除「訴訟費用」或指定「無償代理人」之聲請。但是，在抽象法規審查事件中，因為原則上系爭法令並沒有直接對聲請人產生權利侵害或法律上之不利益，所以通常均不符合聲請無償訴訟進行之要件²⁹。

但是，瑞士聯邦法院卻用判例創造出在抽象法規審查事件中，得例外准許無償司法扶助之要件：首先，當事人須即將面臨著一個適用該系爭法令之行政處分；其次，當事人需無法有效防衛自己之權利。簡言之：聲請人防衛法令之生效施行須具有「即時性」及「具體個人權利受侵害」之虞，而非僅具有受影響之「期待」（*virtueller Betroffenheit*），例如：前揭蘇黎世大學醫學系學生針對該生所屬大學修改「學費收取標準辦法」（*Studiengebührenverordnung*），提起抽象法規審查，請求預防性撤銷該辦法之訴訟，聯邦法院認為其聲請符合前揭二個例外要件，故准許無償之司法扶助³⁰。

七、停止執行效力

依瑞士聯邦行政程序法第55條第1項規定，凡人民提起撤銷具體行政處分訴訟或爭議時（如：訴願提起），原則上具有執行停止之效（即具有阻礙執行之效力），其主要理由依據為：1. 行政處分只有在其合法性經終局確定後，始得執行；2. 如果在行政救濟繫屬

29 Vgl. *Conne* (Fn. 6), S. 412.

30 Vgl. BGE 139, I, 138E. 4.2.

中加以執行，會使得行政救濟制度功能形同夢幻（*illusorisch*）一般；3. 執行停止係邏輯上及理性上的結果狀態；4. 確保法治國家中，人民存在行政處分的權利保護可能性³¹。

但是，在抽象法規審查事件中，得否比照撤銷行政處分訴訟之規定，使其亦得享有執行停止之暫時保護權利之效力呢？此一問題涉及行政法院就利益衡量會產生進退兩難之困擾。申言之，若比照行政處分撤銷訴訟，採原則上執行停止（或效力停止）規定的話，則會造成延遲法令適用期，使立法程序受到不必要之遲延或耽誤；相反地，若採效力不停止原則的話，因行政機關仍得適用系爭法令作成無數行政處分，萬一行政法院認該法令不合上級法令並加以撤銷時，如何溯及回復無以數計的當事人權利受損？此種兩難矛盾，與行政處分撤銷訴訟，性質上之理由完全不同³²。

對此一兩難困境，瑞士Zürich邦行政法官Plüss就舉德國聯邦憲法法院有關「共同生活伴侶法」（*Lebenspartnerschaftsgesetz*），於2011年7月18日所作的判決為例³³加以說明：本件係由同性伴侶所提起的抽象法規審查案，因為「共同生活伴侶法」所保護之伴侶僅限「異性」伴侶，不含「同性伴侶」，基於德國基本法上之平等原則，乃抽象聲請聯邦憲法法院審查該法律違憲，並請求停止該系爭法律之效力，結果德國聯邦憲法法院以5票對3票的結果，裁定不停止該法之效力，結果造成憲法訴願人在繼承法及外國人法上無法回復之損害，即同性外國伴侶被驅逐出境；若該裁定准許該法暫時停止其效力的話，也會造成德國境內更多「異性」共同生活伴侶無法回復之權利損害，所以進退兩難³⁴。比較理想的解決辦法應規定：

31 Vgl. Fritz Gygi, Aufschiebende Wirkung und vorsorgliche Maßnahmen in der Verwaltungsrechtspflege, ZBI 1976, S. 1 (5 ff.).

32 Vgl. Xaver Baumberger, Aufschiebende Wirkung bundesrechtlicher Rechtsmittel im öffentlichen Recht, 2006, S. 202.

33 Vgl. BverfGE 104, 51.

34 Vgl. Kaspar Plüss, Aufschiebende Wirkung im Verfahren der abstrakten

立法者在法律公布後，留下一段較長的準備施行期間，使受法律影響的人有充裕的時間，可以等待抽象法規審查裁判結果之出現，但在立法之現實情況中，立法者卻不太可能預留過長的準備施行期間，所以此種解套方法只有理論上之可行性³⁵。

瑞士聯邦及各邦之行政法院法（如：聯邦行政法院法第103條第1項）或行政審判法大都明文規定：提起抽象法規審查不具有停止效力³⁶。只有少數邦，例如：Zürich邦、Waadt邦及Jura邦之行政審判法明文規定（例如：Zürich邦行政審判法第25條第1項及第3項規定），若有「特殊理由」（aus besonderen Gründen）時，得停止系爭法令之效力。此種特殊理由，尤其是當系爭法律具有特別威脅到個人之權利及法律上之利益，且會伴隨著不可回復之損害或不利益的時候（irreversiblen Nachteilen），為確保法律安定性，乃例外允許系爭法令停止其效力³⁷。例如：動物保護法令修改使得瑞士所有比特犬（Pitbull）都須強制絕育，即屬適例，例外允許有停止效力，以免絕育後，對比特犬形成不可回復之損害。

瑞士及德國制度上大部分採取提起抽象法規審查，原則上不停止系爭法令效力之主要理由為：

1. 抽象法令通常不會對個別當事人造成即時性之影響：因其對一般大眾均具有拘束力。
2. 法令規範之制定者，通常為國會或各邦議會，比行政處分之作成機關，擁有較高之民主正當性。

Normenkontrolle, ZBI 2014, S. 416.

35 Plüss並舉瑞士Zürich邦具爭議性的「交通規費收取辦法」為例，其公布至生效施行期間只有短短8個月而已。Vgl. Plüss (Fn. 34), S. 416.

36 德國聯邦憲法法院法第32條及德國行政法院法第47條第6項亦規定，提起抽象法規審查，原則上並不具有效力停止的明文。

37 此亦為瑞士聯邦法院判決之見解。Vgl. BGE 5. 11. 2001, 2p. 263/2001, E 2b/bb.

3. 如果採取效力停止原則，可能會造成權利濫用而重大影響公益之虞！

此種採取原則上不具有停止系爭法令效力，例外才允許在特殊情況下停止系爭法令之效力，受到比較多國家及邦之採用，似有其實務上及理論上之考量及正當性³⁸。值得我國未來修正行政訴訟法時之參考。

肆、結語

我國司法院「行政訴訟規範審查制度研究修正委員會」自成立以來，即在召集人林錫堯前大法官之引導下，密集開了21次會議（截至2018年10月底前），擬在行政訴訟法第二篇第五章中增訂「都市計畫審查程序」（即增訂於行政訴訟法第237條之18至31後），以因應司法院釋字第742號解釋，要求在2018年12月9日前完成修法之「立法建議」³⁹。所以，對於外國之「抽象法規審查制度」亦有加以比較分析之價值，而不僅參考德國行政法院法第47條規定而已。綜合分析瑞士聯邦及各邦之抽象法規審查制度，可以得知下列初步成果，足供我國行政訴訟法修改之參考：

- 一、抽象法規審查與具體法規審查並不相同，前者不以有個別行政處分違法存在為前提，後者即須有個案存在。我國目前司法院大法官（或未來之憲法訴訟）及一般法院原則上都已享有「抽象」及部分「具體」之法規審查權，但抽象法規審查權是瑞士行政法院比較晚近才發展出的制度，其

³⁸ Vgl. Plüss (Fn. 34), S. 419.

³⁹ 得參見司法院，行政訴訟法研議設都市計畫審查程序專章（第237條之18至237條之31）已完成草案條文初稿，司法周刊，1914期（2018年）。該草案已於2020年1月15日修正公布，並於同年7月1日正式施行。

主要目的在擴大保障人民權利救濟機會，使得人民得就抽象法規，仍得逕行提起行政訴訟，與我國司法院釋字第742號解釋意旨相類似。

- 二、抽象法規審查係屬非典型之司法活動與任務，與具體行政處分違法之審查性質並不相同。其在審查標的、人民提起之合法要件（訴訟要件）、法院審判權限、訴訟費用、司法扶助及停止執行效力上，本質上均都應有所不同規範。
- 三、在審查標的上，因抽象法規審查之系爭標的為一般性之開放性法令（含都市計畫之公布及變更）而非特定具體之行政處分，所以行政法院在違法性之審查上，法官格外不易操作，因其具有無限的可能要件事實類型，而非特定之要件事實。
- 四、人民提起抽象法規審查之訴訟要件，僅須具備其「權利」或「法律上利益」可能受到直接影響者，即為已足，此種「可能性」與具體行政處分之「即時不法侵害」程度上並不相同。但我國行政訴訟法修正草案似仍有門檻之訴訟要件設計。
- 五、行政法院在審查抽象法規之合法性要件時，與具體行政處分之審查並不相同，基於權力分立原則，法院應採取較保守審查之態度，而非全面性高密度審查。申言之，凡法規內之裁量規範，行政法院原則上均應予以尊重；當法規內容不清楚或有二種以上含義或有法規漏洞時，更應作合憲性解釋。
- 六、抽象法規審查之訴訟費用，瑞士法院見解認為原則上亦應比照具體行政處分之收費標準加以收取，不宜調高其訴訟費用，因其訴訟具有公益性質（但非純公益訴訟）。

七、抽象法規審查之無償司法扶助，原則上要件並不具備，但例外情形當聲請人即將面臨適用系爭法令而受有行政處分，且當事人無法有效防衛其自身權利時，即得允許給予無償司法扶助。此種規定，似得於行政訴訟法上加以明定，以利遵循。

八、抽象法規審查原則上不具有停止系爭法令之效力，只有在例外特殊情形，當系爭法令具有「特別威脅」到個人權利及法律上利益，且伴隨著不能回復之損害，方得例外准許法令效力之停止，以暫時保護當事人之權益。我國行政法院目前見解對「不能回復損害」要件認定過嚴，凡認得以「金錢予以彌補者」，均非屬「不能回復之損害」，致人民通常均無法及時獲得有效之「權利暫時保護」。

依據瑞士行政法院審查抽象法規審判之經驗顯示：絕大部分之受理案件，均因法令抽象性高，而享有合法性（或合憲性）推定之裁判結果；只有法令規定內容「完全空白抽象」或「過低開放內容」的可能性，才會例外被行政法院宣告為違反上位法規範。此時，與使用「比例原則」審查「不確定法律概念」有幾分的類似性⁴⁰，從而，規範審查結果，常繫諸系爭法令之開放性高低而定。此一審判實務經驗，也似給我們的立法技術上了一門有用的課，要抱持法令規範之「適度開放性」及必要形成空間不能過高抽象，也不能過低具體化。所以得以我國地方性電動遊戲場業管理自治條例，所設計之距離學校、醫院、圖書館固定距離以上之規定，即屬不明智且欠缺開放性要件之負面法令案例，得引為殷鑑，因其可能被宣告與上位中央法規範相互抵觸（併得參閱司法院釋字第738號解釋）⁴¹。

40 Vgl. Plüss (Fn. 15), S. 424 f.

41 司法院釋字第738號解釋文雖云：「臺北市電子遊戲場業設置管理自治條例第五

我國都市計畫之公布與變更，尤其是通盤檢討變更，具有高度的形成自由與空間，例如：公共設施之設置地點及面積大小，都市土地使用分區之指定及變動（住宅區或保護區）均充滿著高度政策及價值決定，行政法院如何審查其內容形成違法或違憲？法官是否具有相關專業能力？得否取代行政權？都是未來必須面對的難題，實不可掉以輕心或視而不見，否則將無法有效正當化司法判決的公信力。

條第一項第二款規定：電子遊戲場業之營業場所應符合下列規定：……二 限制級：……應距離幼稚園、國民中、小學、高中、職校、醫院、圖書館一千公尺以上。臺北縣電子遊戲場業設置自治條例第四條第一項規定：……應距離國民中、小學、高中、職校、醫院九百九十公尺以上。及桃園縣電子遊戲場業設置自治條例第四條第一項規定……應距離國民中、小學、高中、職校、醫院八百公尺以上。皆未違反憲法中央與地方權限劃分原則、法律保留原則及比例原則。惟各地方自治團體就電子遊戲場業營業場所距離限制之規定，允宜配合客觀環境及規範效果之變遷，隨時檢討而為合理之調整，以免產生實質阻絕之效果，併此指明。」但是主文與「併予指明」之論述，似相互矛盾，實因現行規定已違反比例原則，而屬違憲性質之「阻絕規定」，本號大法官解釋之合憲宣告實不足為訓！

參考文獻

1. 中文部分

司法院（2018），行政訴訟法研議設都市計畫審查程序專章已完成草案條文初稿，司法周刊，1914期。

林明鏘（2018），都市計畫審查通盤檢討變更之司法救濟——評析釋字第742號解釋，月旦裁判時報，68期，頁60-77。

傅玲靜（2019），都市計畫救濟制度之變革及審查密度——「以行政訴訟法修正草案」為中心，第16屆公法研討會，最高行政法院、東吳大學法學院公法研究中心主辦，2019年5月4日。

2. 外文部分

Baumberger, Xaver (2006), Aufschiebende Wirkung bundesrechtlicher Rechtsmittel im öffentlichen Recht, Zürich: Schulthess.

Conne, Andreas (2014), Abstrakte Normenkontrolle im Kanton Zürich: Überblick und Vergleich mit der Einzelaktkontrolle, ZBI, S. 403-413.

Kälin, Walter (1994), Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde (1984), 2. Aufl., Bern: Stämpfli Verlag.

Moser, André/Beusch, Michael/Kneubühler, Lorenz (2008), Ausgewählte prozessrechtliche Fragen im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, ZBI, S. 1-39.

Neumann, Werner (2018), in: Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), VwVfG Kommentar, 9. Aufl., München: C. H. Beck, § 72.

Plüss, Kaspar (2014), Aufschiebende Wirkung im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle, ZBI, S. 414-419.

——— (2014), Kognition im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle,

ZBI, S. 420-425.

Schenke, Wolf-Rüdiger/Schenke, Ralf P. (2017), in: Kopp/Schenke (Hrsg.), Verwaltungsgerichtsordnung: VwGO, 23. Aufl., München: C. H. Beck, § 47.

Schmidt, Jörg (2019), in: Eyermann (Hrsg.), Verwaltungsgerichtsordnung, 15. Aufl, München: C. H. Beck, § 47.

Gygi, Fritz (1976). Aufschiebende Wirkung und vorsorgliche Maßnahmen in der Verwaltungsrechtspflege, ZBI, S. 1 f.